

UNIDAD TRES

“EL PODER CONSTITUYENTE”

Prof. Alcides C. Fortunato

(Comisión nº 2)

Abordaremos en este punto el denominado Poder Constituyente. Resulta práctico a los efectos de una mejor comprensión, calibrar los conceptos que reiteradamente utilizaremos en este trabajo. Decimos “Poder”, como decimos “Constituyente”, y como sucede con todos los términos de uso en las disciplinas humanísticas, pueden abarcar más de un significado.

Poder: El concepto de PODER, reducido a su mínima expresión, significa la capacidad, la facultad, la potestad que tiene alguien respecto de otro, de obtener de él un acatamiento, un “hacer” o “no hacer” algo. Es un vínculo encuadrado en relación de mando-obediencia.

Cuando hablamos de Poder Estatal, nos estamos refiriendo justamente a esa potestad en el ámbito del ente Estado y que justamente constituye uno de los elementos esenciales del mismo, junto al territorio y el componente humano, y es esa “energía” por la que estado impone decisiones de carácter general, aún de manera coactiva, rigiendo así al componente humano, la población, contenida en el elemento geográfico (el territorio). El poder estatal se ejerce, tal como lo veremos ampliado en otros puntos de este curso, a través de los órganos que conforman “el gobierno”.

Explicar el *origen del poder*, ha dado lugar a múltiples y polémicas posiciones. Para algunos, el poder procede de Dios y recae directamente en la persona elegida para ejercerlo. Esta teoría sirvió de base a las monarquías absolutas y a los regímenes de gobierno autocrático de persona o grupo. Otros muchos autores restringen o niegan el origen divino del poder, y lo ponen en cabeza de la comunidad. Así John Locke en

su “*Segundo Tratado sobre Gobierno Civil*” (1689) sostiene que “El fundamento del poder civil es el consenso, por estar dirigido en el interés de los gobernados” y que el poder legítimo solo puede surgir de la voluntad libremente expresada de los miembros de la comunidad. Jean Jaques Rousseau, en su “*Teoría Del Contrato Social*” (1762), dice que el poder es un “atributo del pueblo”, que es delegado a una constituyente con las formas constitucionalmente establecidas. Resulta interesante agregar el concepto que aportara hace pocas décadas el alemán Niklas Lahuman: “El poder es un medio de comunicación generalizado simbólicamente que hace probable la aceptación de acciones de Alter (el otro superior en poder) como premisas y vínculos para las acciones de Ego (el inferior en poder)”

Constituyente: Viene conceptualmente de “constituir” o sea dar forma a algo. El Diccionario de la RAE dice sobre el vocablo: “*Formar o componer [algo]', 'ser algo', 'dotar(se) de una nueva condición o estado*”.

Dentro del ámbito del estado, es justamente el darle a éste una organización, una estructura normativa, abarcante tanto de lo ideológico como de lo funcional del mismo.

PODER CONSTITUYENTE: No resulta extraño que la expresión se desarrollase contemporáneamente con la Revolución Francesa, en tanto la misma fue un cambio de “régimen” y por tanto la necesidad de establecer, de constituir un nuevo “estado”. Emmanuel Joseph Sieyès, noble y sacerdote devenido en activo revolucionario, fue el primero en teorizar sobre el poder constituyente y define el Poder Constituyente como la *potestad que tiene un pueblo de constituir un Estado y de darse la organización jurídica y política que más le convenga*.

Para Carlos Sánchez Viamonte el poder constituyente es la *soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa en cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado para dar nacimiento y personalidad, y para crear sus órganos de expresión necesarias*.

Jorge Reinaldo Vanossi define al poder constituyente como *voluntad primera de un pueblo que no ha tenido organización jurídica o de aquella teniéndola, decide cambiar la filosofía jurídico-política de su orden*

constitucional o también de aquel pueblo que independizado, busca construir una sociedad organizada y soberana, dando forma y expresión a esa mediante una Constitución.

PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO y PODER CONSTITUYENTE

DERIVADO:

En doctrina constitucional se distinguen dos “momentos” del ejercicio del Poder Constituyente:

Poder Constituyente Originario: Es el que el cuerpo social ejerce en la etapa fundacional del Estado, dándole nacimiento y estructura. En esta etapa la “comunidad”, entendida como el conjunto de seres humanos que la integran, es la titular del Poder Constituyente, decidiendo que tipo de organización jurídico política darán al estado que se crea. Esto se vincula de manera importante con el concepto de “legitimidad”, es decir cómo percibe la mayoría del cuerpo comunitario, depositario nominal del poder constituyente, a aquellos que por estar efectivamente en condiciones de determinar la estructura fundacional, son los que la van a llevar adelante.

En cuanto a los alcances del ejercicio de este Poder Constituyente Originario, dependerá de las circunstancias del momento en la comunidad que este destinada a regir. Si bien puede decirse que no está sometido a ninguna norma jurídica precedente, las características propias de esa sociedad, en ese momento y lugar resultaran factores de influencia, así como otras influencias indiscutibles, tales las que derivan del Derecho Natural (Valores de justicia, libertad, etc) o las del Derecho Internacional, pues son hay que olvidarse que el estado “convive” con otros entes, públicos y privados, en el contexto internacional.

Dadas las características de los eventos políticos que dieron lugar a la sanción de la Constitución de 1853, donde la Provincia de Bs. As se desprende de la Confederación Argentina, a la que vuelve luego de negociaciones y previa reforma de la misma en 1860, MAYORITARIAMENTE ENTIENDE NUESTRA DOCTRINA CONSTITUCIONAL QUE EL PERIODO DE EJERCICIO DE PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO EN ARGENTINA, ABARCA PUES EL LAPSO 1853-1860

Poder Constituyente Derivado:

Es el que se ejerce cuando ya el Estado tiene un orden constitucional, en virtud del cual se efectúan cambios a las normas constitucionales, y por tanto está sujeto a procedimiento, condiciones y hasta prohibiciones que la constitución precedente puede contener. Hay en tal sentido una “limitación” más marcada en su ejercicio.-

LÍMITES AL PODER CONSTITUYENTE DERIVADO- LA CUESTION DE LAS CLAUSULAS “PETREAS”:

Presumiendo la agudeza universitaria de Uds. creo que habrán descubierto ya, lo de petra tiene que ver con concepto de duradero, de sólido y por tanto con la limitación, en definitiva, a las reformas que se pueden hacer por la vía del Poder Constituyente Derivado. Sostienen algunos autores que hay normas establecidas en las constituciones Originarias, que no pueden ser tocadas en una reforma posterior. Explican esto diciendo que son normas que se arraigan en la cultura jurídica del estado y que no pueden alterarse. Por ejemplo la Democracia, la República etc. Otra corriente doctrinaria sostiene que vedar por vía de la petrificación normas constitucionales válidas para una generación a otras futuras, no sería legítimo en tanto impida cambio de régimen o una manera de regularse, salvo que la petrificación se circunscriba a “normas que reconociese al hombre derecho a su dignidad” (Sagues, Pedro N. Elementos de Derecho Constitucional Tº 1 p 107). Un interesante ejemplo es lo que ocurrió en 1853, cuando se ejerció el Poder Constituyente originario en Argentina y para tratar de que se “solidificara” ese importante paso legal de darnos constitución, que demoró casi cuatro décadas de sangre y muerte, el texto estableció la prohibición de reforma por un lapso de diez años (vencía en 1863). Sin embargo, la realidad impuesta por la deserción de la Pcia. Bs.As, que se separó de la Confederación Argentina, y las negociaciones posteriores para que se reincorporara, hicieron que se convocara a Reforma (Poder Const. Derivado) en 1860, lo que fue consensuado y así ocurrió.-

REFORMA DE LA CONSTITUCION ARGENTINA:

Entrando al procedimiento de REFORMA (recordemos que es el ejercicio del Poder Constituyente Derivado), debemos puntualizar, haciendo comparación de las distintas Constituciones, que podemos agruparlas en dos sistemas:

Sistema Flexible de Reforma: En este sistema, para reformar la Constitución, se utiliza el mismo mecanismo que para sancionar las leyes. Puede haber o no algún agregado al procedimiento, pero lo que lo caracteriza es que el mismo órgano legislativo (Parlamento o Congreso) hace la reforma. Tal el caso de EE.UU. La Constitución establece que es el Congreso que reforma la constitución (“enmienda” le llama) y que luego debe ser sometida a la aprobación de cada uno de los estados que integran la unión. Cuando la mitad más uno la aprueba, entra en vigencia. (A título de anécdota y por conocida, debe mencionarse la famosa enmienda XVIII llamada “de la ley seca”, que prohibió en 1920 la producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, dando lugar a toda una industria clandestina reflejada en cine y novelas. Rigió hasta 1933.

Sistema Rígido de Reforma. Se da cuando la Constitución establece para su reforma, un procedimiento especial, distinto del normal y habitual que ha creado para la formación de las leyes. Es por el que optó nuestro país, ya que el Art. 30 dice **“La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de Reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto”.-**

Como se advierte, el artículo dice que se puede reformar en “..el todo o en cualquiera de sus partes”, lo cual parece despejar la duda sobre las cláusulas pétreas, y dejarlas limitadas a lo que la sociedad entienda por intocable en un momento determinado. También es de resaltar que si bien la reforma en si misma va a ser realizada por un órgano especial (CONVENCION convocada al efecto), hay una intervención del Poder legislativo previa, que es la DECLARACION DE NECESIDAD DE REFORMA por parte del Congreso Nacional, con mayorías agravadas (más votos requeridos que los que necesitan las leyes comunes).

Dado lo sintético del artículo 30 y la magnitud de lo que implica una reforma constitucional, han surgido problemas de interpretación, ya que no dice como se compone la Convención Reformadora, aunque la tradición ha impuesto por así haberlo sido en todas las oportunidades, mediante elección popular. Deja abiertas también cuestiones tales como si el congreso debe tratar la Ley de Necesidad de Reforma por separado o en Asamblea Legislativa (sesión conjunta), si los dos tercios de los presentes requeridos lo son sobre los que efectivamente están dando quórum o sobre el total de miembros de la Cámara. Otro tema no menor es si la Convención puede apartarse de los puntos que la Ley de Necesidad de Reforma establece, y efectuar reforma sobre otros aspectos o sobre el total, entendiendo que ha renacido en ella el poder constituyente Originario.

LAS REFORMAS A LA CONSTITUCION NACIONAL A TRAVES DEL TIEMPO:

Decir a esta altura que la Constitución, en su doble rol de ley suprema que organiza política y jurídicamente el estado y a su vez establece derechos y garantías para los habitantes debe seguir la evolución de la sociedad a que está destinada a regir, y que las reforma periódica, su “aggiornamento” (perdonaran el italianicismo) es imprescindible, parecería obvio. Sin embargo en nuestro país no ha sido así. Varias realidades han contribuido al envejecimiento de la Constitución, sobre todo en el siglo XX, siendo la más evidente, el tópico de la reelección del titular del ejecutivo. Ello redundaba en problemas que en forzosa comparación podríamos paralelar con aquel niño al que al no adaptarse su esqueleto al crecimiento orgánico, se ve invalidado. Aparecen así multiplicadas, las denominadas MUTACIONES CONSTITUCIONALES, que son cambios que operan en la realidad del mundo jurídico pero no son recogidas formalmente en la Constitución. Un ejemplo por la vía del absurdo: Nuestra CN establecía, hasta su reforma en 1994, que el Presidente debía residir en la capital de la Republica, y que solo podía ausentarse de la misma con autorización del Congreso. Sabido es que desde mediados del siglo XX, el Presidente tiene su residencia oficial en la Quinta de Olivos, Partido de Vicente López, Pcia de BsAs, por lo que salía y entraban cada día de jurisdicción.

Las MUTACIONES CONSTITUCIONALES se suelen clasificar en MUTACIONES POR ADICCIÓN y MUTACIONES CONSTITUCIONALES POR SUSTRACCIÓN:

Las por ADICCIÓN: Son circunstancias no previstas que se “normalizan” y se tienen por válidas (Así la existencia real, y obligatoriedad de los Partidos Políticos de canalizar a través suyo las postulaciones, que las leyes han contenido, siendo que hasta 1994 no se mencionaban en la Constitución)

Las por SUSTRACCIÓN: Cuando una norma o institución pierde vigencia porque una costumbre distinta se ha impuesto o porque ha caído en desuso. Así toda la normativa que perduró en nuestra Constitución escrita, referida a las comunicaciones religiosas y nombramientos de obispos etc de la Iglesia católica (Derecho de Patronato) siendo que habían sido acotadas o extinguido por acuerdos entre nuestro país y el Estado Pontificio.

BREVE DETALLE DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES ARGENTINAS DESDE 1853

CONSTITUCION DE 1853: (Convención reunida en Santa Fé)

El 31 de mayo de 1852, vencido Rosas en Caseros, las provincias integrantes de la Confederación Argentina firmaron el Acuerdo de San Nicolás, por el que convocaron a un Congreso Constituyente. Sin embargo el 11 de septiembre la Provincia de Buenos Aires se separó de la Confederación, ya que Buenos Aires no aceptó transferir el poder que se le reservaba, sobre todo en lo concerniente a la igualdad de representación en el congreso (dos diputados por provincia y a la nacionalización de la aduana anunciada en el artículo 19 del Pacto de San Nicolás), por tanto no participó del Congreso. La Constitución fue aprobada sin Bs. As el 1 de mayo de 1853 en la Ciudad de Santa Fe y jurada el 25 de mayo de ese año, rigiendo solo para las trece provincias restantes. Recién en 1859 y luego de la batalla de Pavón, Buenos Aires y la

Confederación se reunificarían y aceptan revisar la Constitución, lo que da lugar a la Reforma de 1860.

REFORMA DE 1860 (Convención reunida en Buenos Aires)

La reforma constitucional de 1860 fue resultado del Pacto de San José de Flores, en el cual Buenos Aires volvió a ser parte de la Confederación Argentina y en el que se estableció que la provincia porteña podría proponer reformas a la Constitución Nacional de 1853, que establecía la forma de gobierno federal, para que fueran evaluadas por una Convención Constituyente Ad Hoc. La reforma se hizo sin respetar la prohibición, como ya se dijo más arriba, de reformar la Constitución antes de cumplirse diez años de su sanción, requisito establecido en el artículo 30 del texto constitucional de 1853. Las principales modificaciones fueron: 1) La eliminación del artículo que establecía que la Capital Federal sería la ciudad de Buenos Aires, 2) La obligación de que los derechos de importación sean uniformes en todo el país (con el fin de impedir que se promuevan determinadas regiones o puertos), 3) La eliminación por cinco años de los derechos de exportación, la reducción de facultades del gobierno nacional para intervenir provincias, decretar el estado de sitio, someter a juicio político a los gobernadores, diputados y senadores nacionales, o revisar las constituciones provinciales. 4) La prohibición al Congreso nacional de dictar leyes que "restringan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal", 5) El reconocimiento de los derechos y garantías implícitos derivados del principio republicano y de soberanía del pueblo. 6) El reconocimiento del principio de "ciudadanía natural" (jus soli). Elimino del texto original las facultades de la Corte Suprema de la Nación en conflictos entre poderes públicos de una misma provincia, o entre una provincia y sus vecinos.

Reforma de 1866 (Convención reunida en Buenos Aires)

La reforma constitucional de 1866 estuvo motivada por reordenar los ingresos del Estado nacional, e impulsada por el presidente Mitre al

solo efecto de mantener vigentes los impuestos a las exportaciones, llamados también retenciones o derechos de exportación, que habían caducado a partir del 1 de enero de 1866 por que así lo estableció la reforma constitucional de 1860. La reforma modificó dos artículos: el artículo 4, para eliminar el vencimiento de 1866, y el artículo 67, inciso primero, para restablecer la facultad de Congreso Nacional para imponerlos.

Reforma de 1898 (Convención reunida en Buenos Aires)

La motivó la necesidad de adecuar la Constitución al crecimiento del país. Amplió la base poblacional para la elección de diputados nacionales y modificó la Ley de Ministerios (fijo su número en ocho, lo que a la larga trajo problemas cuando siguió creciendo el país)

Reforma de 1949 (Convención reunida en Buenos Aires)

Concreto la incorporación nuevos derechos sociales (los de segunda generación) y las nuevas funciones del Estado desde la óptica del “estado de bienestar”. Fue promovida por el gobierno de Juan Perón. Reconoció la igualdad jurídica del hombre y la mujer, incorporó la función social de la propiedad, estableció la autonomía universitaria, los derechos de la niñez y la ancianidad, el hábeas corpus, derechos laborales (entre los que curiosamente no incluyó el Derecho de Huelga) así como facultades de intervención de Estado en la economía, entre otras normas. También estableció la reelección indefinida del presidente, cuyo mandato era de seis años (Tema que no estaba contemplado en el temario de la ley de reforma dictada por el Congreso)

MODIFICACION DE FACTO Proclama militar de 1956

El 27 de abril de 1956 el Gobierno de facto surgido del derrocamiento de Perón, emitió una proclama de carácter constitucional,

declarando “vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898, y exclusión de la de 1949”

MODIFICACION “DE FACTO” de 1957

En un hecho inédito, la dictadura encabezada por el general Aramburu por decreto 3838 estableció “la necesidad de reformar la Constitución” y convocó a elecciones de convencionales constituyentes para convalidar la derogación de las reformas de 1949 y realizar, eventualmente, nuevas reformas constitucionales. El gobierno militar prohibió la presentación de candidatos peronistas, pero sus simpatizantes respondieron votando masivamente en blanco y obteniendo la mayoría, hecho que afectó fuertemente la legitimidad de la Convención Constituyente. Por su parte la Unión Cívica Radical se fragmentó en dos partidos, Unión Cívica Radical Intransigente (liderada de quien más adelante habría de ser el Presidente Frondizi) y Unión Cívica Radical del Pueblo (seguidores de Ricardo Balbín),

La Asamblea Constituyente se limitó a convalidar la decisión del gobierno militar e inmediatamente después los convencionales comenzaron a retirarse sin tratar las reformas preparadas por las comisiones. Mientras los representantes se retiraban, una parte logró sancionar el artículo 14 bis, referido a los Derechos Sociales, convertido este artículo “ómnibus” en la inserción del Constitucionalismo Social en el marco del texto de 1853, curiosamente por vía de un gobierno de facto.

Estatuto de la Revolución Argentina de 1966-1973

El 28 de junio de 1966, mediante un golpe de Estado, asumió el poder una junta militar que se autodenominó Revolución Argentina y dictó un Estatuto de la Revolución Argentina integrado por 10 artículos que tenía preeminencia sobre la Constitución Nacional de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, que permaneció vigente, aunque

sin el carácter de norma suprema. El Estatuto de la Revolución Argentina quedó de hecho sin efecto el 25 de mayo de 1973, al asumir las autoridades democráticas surgidas del acto electoral del 11 de marzo de ese año, y que juraron por la Constitución de 1853 y sus reformas

Estatuto Fundamental Temporario de 1972

El 24 de agosto de 1972 la Junta de Comandantes que gobernaba la dictadura autodenominada Revolución Argentina y que dio lugar a tres presidentes de facto, (los militares Onganía, Levingston y Lanusse) dictó un “Estatuto Fundamental” de cinco artículos, manifestando explícitamente que se hacía en “ejercicio del poder constituyente”, que incluía una serie de considerandos y reformó quince artículos de la Constitución (texto de acuerdo a la reforma de 1957), al mismo tiempo que declaró inaplicables otros cuatro artículos, con miras a hacer más operativa, habida cuenta de que se convocaba a elecciones para 1973 (de cuyo resultado resultarían electos Cámpora y luego Juan Perón). Algunas de sus reformas fueron recogidas décadas más tarde al reformarse la Constitución en 1994. Entre otras se estableció: 1) Reducción del mandato del presidente, vicepresidente, diputados y senadores a cuatro años 2) Reección del presidente por una vez. 3) Reección indefinida de diputados y senadores. 4) Elección directa de presidente, vicepresidente, diputados y senadores. 5) Creación del cargo de tercer senador por la minoría. 6) La simultaneidad de las elecciones para cargos nacionales 7) Estableció la aprobación de leyes directamente por las comisiones internas de las Cámaras 7) Creó un organismo especial para realizar el juicio político a los jueces integrado por miembros del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los abogados.

Las elecciones de 1973 (11 de marzo: Cámpora y 27 de septiembre: Perón, y las autoridades democráticas surgidas de ellas se regularon por esta reforma. El Estatuto establecía que el mismo regiría hasta el 24 de mayo de 1981, fecha en que automáticamente quedaría sin vigencia sino era ratificado por una convención. Notoriamente, casi la totalidad de los

cambios vigentes entonces fueron incorporados a la Constitución en la reforma de 1994.

Reforma de 1994 – (Convención reunida en las ciudades de Santa Fe y Paraná

Luego del golpe de estado producido el 24 de marzo de 1976, con el retorno a la vigencia democrática plena ocurrida el 10 de diciembre de 1983 bajo imperio de la Constitución de 1853, la evidente necesidad de reforma no llegó a plasmarse sino hasta que la coyuntura impuesta por las fueras mayoritarias y sus trasfondos, lo posibilitó en 1994 La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 es la última de las realizadas a la fecha. Blanqueó el texto constitucional, despejando las dudas sobre su legitimidad plena y respecto de las cuales no existía consenso, y en un novedoso giro, le otorgó rango constitucional a los principales tratados de derechos humanos.

La reforma se concretó a partir de un pacto entre peronistas (Menem) y radicales (Alfonsín), que por entonces eran los dos partidos mayoritarios del país, y en el que ambos partidos acordaron un "Núcleo de Coincidencias Básicas" para incluir en la Constitución, que debió ser votado "en bloque" por la Convención, sin poder realizar agregados ni quitas.

Entre otros cambios de modernización, incorporó nuevos Derechos y Garantías, amplió los de segunda generación y receptó los de tercera generación, fijó normas para defensa de la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno, y nuevos órganos de control. La Convención Constituyente se celebró simbólicamente y de manera simultánea, en las ciudades de Santa Fe (sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná (primera capital de la Confederación).

Esta reforma constitucional abarca 44 artículos y tiene 17 disposiciones transitorias, alguna de la cual a pesar del tiempo transcurrido, no se han cumplido (ley de Coparticipación Federal) de la que el Senado

está en mora desde 1996 según Cláusula Transitoria sexta de la Constitución Nacional.